

次の1から5までの各記述のうち、事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解の根拠となり得るものを2個選びなさい。

1. 窃盗の実行に着手した後、財物窃取前に被害者に発見されたため、同人に暴行・脅迫を加えて財物を強取するいわゆる居直り強盗の場合と、事後強盗の場合を、予備段階で区別するのは實際上困難であり、両者の処罰に差異を設けることは妥当でない。
2. 条文の配置上、事後強盗罪の処罰規定が強盗予備罪の処罰規定の後に規定されていることを考慮すべきである。
3. 実質的に窃盗の予備を処罰することになる。
4. 事後強盗罪に関する刑法第238条は、「強盗として論ずる。」と規定している。
5. 事後強盗罪は、窃盗犯人であることを身分とする身分犯であり、身分犯の予備行為は、身分者でなければ行うことができない。

No290	強盗予備		正答率
H24-19	正 解	1、4 (順不同)	85%

1 根拠となり得る

事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解は、強盗目的で予備を行った者を処罰の対象とする強盗予備罪（237 条）の「強盗の目的」には、事後強盗（238 条）の罪を犯す目的も含まれると解するものである。そして、この見解は、居直り強盗の目的と事後強盗の目的の差は紙一重であり、予備段階において、236 条で把握される居直り強盗と事後強盗を区別することは困難であるから、一方のみを予備罪で処罰し他方を処罰しないのは妥当ではないことを論拠の一つとして挙げる。したがって、本記述は事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解の根拠となり得る。

2 根拠となり得ない

事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認めない見解は、予備罪が処罰される場合、通常本罪の後に予備罪の条文が配置されるところ、条文の配列が238 条の前に予備罪があることを理由として、事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を否定する。したがって、本記述は事後強盗罪の予備行為に強盗予備罪の成立を認める根拠とはなり得ない。

3 根拠となり得ない

事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認めない見解は、事後強盗罪は、窃盗の存在しない場合には存在し得ないのであり、窃盗の予備を罰していない刑法の解釈として、事後強盗の予備を考えるのは不都合であるとしている。したがって、本記述は事後強盗罪の予備行為に強盗予備罪の成立を認める根拠とはなり得ない。

4 根拠となり得る

事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める見解は、237 条の「強盗の罪を犯す目的」に事後強盗の目的が含まれることを根拠としている。その理由として、238 条が事後強盗を強盗として論ずると規定していることを挙げている。したがって、本記述は事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認める根拠となり得る。

5 根拠となり得ない

事後強盗の予備行為に強盗予備罪の成立を認めない見解は、事後強盗罪の主体である「窃盗」とは、窃盗の実行行為に着手した者すなわち窃盗犯人をいい、事後強盗は一種の身分犯であるから、窃盗の存在しないところに事後強盗はあり得ず、事後強盗の予備行為に対する強盗予備罪の成立を否定する。したがって、本記述は事後強盗罪の予備行為に強盗予備罪の成立を認める根拠とはなり得ない。